



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



MÉRITO

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 14/08/2024 – SECÇÃO MUNICIPAL

EXAMES PRÉVIOS DE EDITAL

Processos: TC-013596.989.24-4 e TC-013952.989.24-2.

Representantes: - Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda., por seus advogados Rafael Prudente Carvalho Silva (OAB/SP n.º 288.403) e Thiago Ramos Pereira (OAB/SP n.º 274.747); e

- Felipe Dudienas Domingues Pereira (OAB/SP n.º 280.438).

Representada: Prefeitura Municipal de Rancharia.

Responsável: Marcos Slobodticov – Prefeito.

Advogados: Tamae Lyn Kina Marteli (OAB/SP n.º 158.969), Marcio Aparecido Pascotto (OAB/SP n.º 111.636), Lucio Monteiro Junior (OAB/SP n.º 240.384), Carolina de Oliveira Sobral Ramirez dos Santos (OAB/SP n.º 228.546), Karina Martinello Daltio (OAB/SP n.º 194.848) e Gabryela Dias Roma Cavalcante (OAB/SP n.º 322.783).

Assunto: Representações formuladas contra o edital do Pregão Eletrônico n.º 012/2024, Processo Administrativo n.º 043/2024, que objetiva a contratação de empresa especializada no ramo de fornecimento e gerenciamento de vale alimentação e refeição por meio de cartões eletrônicos com senha e chip de segurança, para aquisição de gêneros alimentícios e refeições, destinados aos servidores municipais.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas,

Em exame as Representações formuladas pela **empresa Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda.** e pelo **advogado Felipe Dudienas Domingues Pereira** contra o edital do Pregão Eletrônico n.º 012/2024, Processo Administrativo n.º 043/2024, da Prefeitura de Rancharia, tendo por objeto a contratação de empresa especializada no ramo de fornecimento e gerenciamento de vale alimentação e refeição por meio de cartões eletrônicos com senha e chip de segurança, para aquisição de gêneros alimentícios e refeições, destinados aos servidores municipais.

A peticionária **Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda.**, em linhas gerais, censura as seguintes particularidades do instrumento, citando precedentes em amparo de sua compreensão:

- a) indevida permissão de oferta de taxas de administração negativas (subitem 4.1., alínea “b”¹), em violação ao artigo 3º, inciso I, da Lei Federal n.º 14.442/2022, que proíbe a exigência ou recebimento de qualquer tipo de deságio ou imposição de descontos sobre o valor contratado; e
- b) inapropriada natureza posterior da contrapartida da Administração constante do subitem 11.1², em desconformidade com o disposto no artigo 3º, inciso II, do mesmo diploma, que não autoriza prazos de repasse que descaracterizem a natureza pré-paga dos montantes a serem disponibilizados aos trabalhadores.

¹ 4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos, conforme o caso:

[...]

b) O valor máximo da “taxa de administração” a ser paga, sobre a prestação dos serviços, está limitado, podendo ser positivo, zero ou negativo, mas não poderá ultrapassar o percentual de 1% (um por cento) positivo, em até 2 casas após a vírgula (0,00%).

² 11.1. O MUNICÍPIO pagará à licitante contratada o valor total de recarga efetivamente disponibilizado em cada mês, acrescido da taxa de administração ofertada, de (taxa %), uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais previstas, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do ateste de Recebimento pelos respectivos fiscais do contrato, que deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da respectiva nota fiscal/fatura, relativas aos serviços prestados no período a que o pagamento se referir, desde que tenham sido observadas todas as disposições constantes no Termo de Referência, contido no Anexo I do Edital do Pregão nº 012/2024.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Em conclusão, requer a concessão de medida liminar de paralisação da competição, a fim de que seja determinado o aprimoramento do instrumento nas particularidades combatidas.

De seu turno, o postulante **Felipe Dudienas Domingues Pereira** reclama, em resumo, igualmente da imprópria aceitação de propostas com taxas de administração negativas, conforme nota constante do Anexo II³.

Em arremate, após ponderar que se trata de norma aplicável aos órgãos públicos, em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal, pleiteia a concessão de providência cautelar de suspensão do torneio, com o intuito de, ao final, ser determinada a correção do ato de chamamento.

Considerando a possibilidade do regular exercício do contraditório, vez que o certame se encontrava suspenso por ato voluntário da Administração, assinalou-se à autoridade responsável prazo para a apresentação de justificativas sobre as impropriedades aventadas, acompanhadas de cópia completa do edital censurado.

Devidamente notificado, o Município ofertou esclarecimentos.

De início, noticia que a Lei Federal n.º 14.442/2022 é objeto de ação de controle concentrado no Supremo Tribunal Federal (ADI 7248), na qual se aventa prejuízo à competição em licitação e à busca da proposta mais vantajosa à Administração.

Registra, ainda, decisão do TCU no sentido de que não cabe ao Poder Público limitar a taxa a ser ofertada pelos licitantes.

Tece ponderações sobre o caráter usual, no ramo de fornecimento de cartão alimentação e refeição, da prática de desconto sobre o valor dos créditos, a qual não implica propostas inexequíveis, dadas as outras fontes de lucro das

³ O valor da taxa de administração, constante da planilha proposta deverá ser ofertado em percentual. O percentual poderá ser ofertado em até 2 casas após a vírgula (0,00%). As licitantes poderão ofertar taxa de administração positiva, negativa ou de valor zero.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



fornecedoras.

Salienta que essa praxe representa enorme economia ao erário e é benéfica às empresas, que ampliam suas redes credenciadas e conseguem novos clientes na iniciativa privada.

Consigna que, com a proibição de taxas negativas, todas as licitantes ofertarão proposta com valor zero, sem vantagem para os órgãos públicos, em afronta à busca da proposta mais vantajosa e ao artigo 33 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Prossegue aduzindo que, em casos tais, ocorrerá empate, a demandar o emprego dos critérios de escolha do artigo 60 da Nova Lei de Licitações e Contratos.

Na sequência, articula que a Lei Federal n.º 14.442/2022 não se aplica aos servidores estatutários, porquanto não subordinados ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho.

Compulsando a Exposição de Motivos da Medida Provisória n.º 1.108/2022, depois convertida na lei referida, argumenta que esse regramento não incide no âmbito da Administração Pública, vez que seus órgãos, ainda que inscritos no PAT, não são beneficiários de incentivo fiscal.

Acrescenta a existência de conflito aparente de normas, pois a limitação de taxa contraria princípios basilares das licitações, de sorte que, por critério de especialidade, devem prevalecer os dispositivos que regem as contratações públicas.

No mais, pondera que a Lei Federal n.º 14.442/2022 pode ter sua inconstitucionalidade declarada, em razão de ferir os princípios da liberdade econômica, livre iniciativa e concorrência, tudo a conduzir à inaplicabilidade do artigo 3º de referido diploma aos órgãos públicos.

Dando seguimento, citando o disposto no artigo 5º da Lei Federal n.º 14.133/2021, assim como lição doutrinária, frisa que “*no ramo de fornecimento de*



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Vale Alimentação/Refeição, a proposta mais vantajosa decorre da Taxa Negativa, pois as empresas concedem um desconto no crédito dos cartões, gerando enorme economia aos cofres públicos, recurso este que pode ser revertido à outras políticas públicas.”

Menciona que o sorteio não está previsto como critério de desempate na atual legislação licitatória, porquanto os parâmetros de julgamento são previstos em rol taxativo no artigo 33 do aludido diploma.

De todo modo, anuncia que, como havia divergências na matéria entre corpo principal do edital e termo de referência, optou por suspender o certame para as devidas correções.

Em continuidade, após reproduzir o disposto no artigo 3º, inciso II, da Lei Federal n.º 14.442/2022 e a disciplina do ato convocatório, argumenta que:

“[...] não pode o órgão público vedar a taxa negativa com base na Lei nº. 14.442/2022 e proporcionar prazo para realizar o pagamento, cortando parte da lei.

Portanto, em tese, já que o órgão iria fazer uso de uma lei que não traz nenhum benefício para ela nem para as licitantes, ela deve ser aplicada em sua integralidade, privilegiando o próprio princípio da legalidade, ESTABELECENDO QUE O PAGAMENTO DEVE SER FEITO ANTECIPADAMENTE, OU SEJA, PRÉ-PEGO, conforme preceitua a lei.”

Em conclusão, após retomar as considerações sobre a abrangência de referida norma federal, com argumentos semelhantes aos já expostos, requer seja julgada improcedente a representação e arquivado o feito.

Não obstante as razões de defesa apresentadas, vislumbrou-se, ao menos em tese, apontamento que indica potencial risco à higidez da licitação, em contrariedade às normas de regência da matéria.

Nessas circunstâncias, com amparo nos §§ 1º e 2º do artigo 171 da Lei Federal n.º 14.133/2021, este Egrégio Plenário, em Sessão de 17/07/2024, acolheu proposta de que as matérias fossem recebidas como Exames Prévios de Edital, com a expedição de Ofício pela E. Presidência deste Tribunal, requisitando da Administração representada, no prazo de 10 (dez) dias, cópia completa do edital



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



impugnado, bem como lhe facultando, no mesmo interregno, a apresentação de justificativas complementares acerca de todos os questionamentos aduzidos nas iniciais, determinando-se, ainda, a manutenção da suspensão do certame até apreciação final por parte desta Casa.

Em resposta a Administração limitou-se a encartar aos feitos cópia do instrumento impugnado.

Analisando a matéria, o Ministério Público de Contas firma posição pela procedência parcial da Representação abrigada no TC-013956.989.24-4 e procedência daquela constante do Processo TC-013952.989.24-2.

É o relatório.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 14/08/2024 – SECÇÃO MUNICIPAL

EXAMES PRÉVIOS DE EDITAL

Processos: TC-013596.989.24-4 e TC-013952.989.24-2.

Representantes: - Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda., por seus advogados Rafael Prudente Carvalho Silva (OAB/SP n.º 288.403) e Thiago Ramos Pereira (OAB/SP n.º 274.747); e

- Felipe Dudienas Domingues Pereira (OAB/SP n.º 280.438).

Representada: Prefeitura Municipal de Rancharia.

Responsável: Marcos Slobodticov – Prefeito.

Advogados: Tamae Lyn Kina Marteli (OAB/SP n.º 158.969), Marcio Aparecido Pascotto (OAB/SP n.º 111.636), Lucio Monteiro Junior (OAB/SP n.º 240.384), Carolina de Oliveira Sobral Ramirez dos Santos (OAB/SP n.º 228.546), Karina Martinello Daltio (OAB/SP n.º 194.848) e Gabryela Dias Roma Cavalcante (OAB/SP n.º 322.783).

Assunto: Representações formuladas contra o edital do Pregão Eletrônico n.º 012/2024, Processo Administrativo n.º 043/2024, que objetiva a contratação de empresa especializada no ramo de fornecimento e gerenciamento de vale alimentação e refeição por meio de cartões eletrônicos com senha e chip de segurança, para aquisição de gêneros alimentícios e refeições, destinados aos servidores municipais.

EMENTA: EXAMES PRÉVIOS DE EDITAL. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO. INDEVIDA PREVISÃO DE ACEITAÇÃO DE PROPOSTA COM TAXA NEGATIVA. PROCEDÊNCIA PARCIAL E PROCEDÊNCIA.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas,

Consoante relatado, as impugnações aduzidas pelos representantes referem-se a temas que nos últimos tempos têm se tornado rotineiros nos julgados desta Casa, acerca de procedimentos licitatórios voltados à contratação de serviços de vale alimentação e refeição, sobretudo após a promulgação da Lei nº 14.442/22.

No caso específico, os questionamentos referem-se à possibilidade do oferecimento de propostas com taxa de administração negativa e o pagamento da contratada após a disponibilização dos créditos aos beneficiários.

E bem assim, no que tange ao primeiro aspecto, o entendimento que vem sendo adotado é de que, embora o órgão promotor do certame não esteja inscrito no PAT e os beneficiários não sejam regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, são aplicáveis à espécie as previsões do inciso I do artigo 3º da citada Lei nº 14.442/22⁴, como já se decidiu no Processo TC- 009245.989.22-3, de relatoria do Eminentíssimo Conselheiro Robson Marinho, julgado por este Plenário na Sessão de 06/04/2022, permitindo-me transcrever o seguinte trecho do voto condutor da decisão:

De fato, recorro que em nossa última reunião – dia 23 de março deste ano -, o Plenário, em acolhimento ao r. voto do Eminentíssimo Conselheiro Renato Martins Costa, aceitou a vedação à taxa negativa, especificamente porque naquela situação a CETESB, beneficiária ativa do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador), estaria obrigada a atender aos parâmetros insculpidos no Decreto nº 10.854/21, cujo artigo 175 proíbe o recebimento de qualquer tipo de deságio ou imposição de descontos sobre o valor contratado (TC-5627.989.22-1).

Todavia, compreendo que tal raciocínio possa ser estendido, de forma mais ampla, aos demais Entes promovedores dos certames, independentemente da inscrição naquele programa.

Aliás, esta inteligência não é nova, haja vista que conta, há tempos, com a simpatia especial do Eminentíssimo Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, como retratado nas notas taquigráficas do TC-015950.989.19-4 (Pleno de 31/7/2019), ao indagar se seria razoável a Administração, do ponto de vista

⁴ Art. 3º O empregador, ao contratar pessoa jurídica para o fornecimento do auxílio-alimentação de que trata o art. 2º desta Lei, não poderá exigir ou receber:

I - qualquer tipo de deságio ou imposição de descontos sobre o valor contratado

(...)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



ético, ser parceira das empresas oligopolizadas deste setor, da mesma forma que soaria estranhíssimo, agora do ponto de vista moral, que a disputa ocorresse entre grupos fortíssimos e que a Prefeitura ou o Estado abocanhasse uma parte desses rendimentos.

Como forma de contribuir a este debate, agrego a este contexto que aparentes “prejuízos” decorrentes da concessão de desconto na taxa de administração, por óbvio, não seriam assumidos pelos prestadores do serviço, mas sim, ao menos em certa medida, repassados aos usuários finais – no caso, os servidores da Câmara.

Em outras palavras, haveria uma “usurpação” da finalidade precípua da prestação, haja vista que os seus destinatários estariam impedidos, na prática, do recebimento de tais benefícios pelos valores reais de mercado. Veja-se que se a intenção do Decreto nº 10854/21 foi proteger o trabalhador com a vedação, nada mais justificável, até pelo aspecto de isonomia, estendê-la aos demais beneficiários, mesmo que empregados em entidades não filiadas ao PAT.

A propósito, nesta linha foram as palavras pronunciadas pelo Eminentíssimo Conselheiro Renato Martins Costa naquela oportunidade já mencionada, ao pontuar que, “se a regulamentação federal do PAT caminhou por aí, é um reforço enorme na interpretação da inconveniência, em qualquer circunstância, da adoção de taxa zero ou negativa”.

Também nesse sentido foram as decisões proferidas no Processo TC-010031.989.22-1, em Sessão Plenária de 11/05/2022, sob relatoria do e. Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo; Processos TC-014316.989.22-7 e TC-014428.989.22-2, em Sessão de 06/07/2022, sob relatoria do e. Conselheiro Renato Martins Costa; Processos TC-007673.989.23-2, TC-008340.989.23-5 e TC-008626.989.23-0, em Sessão de 03/05/2023, sob relatoria do e. Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues; e Processos TC-015172.989.24-6 e TC-015427.989.24-9, em Sessão Plenária de 31/07/2024, sob minha relatoria.

Assim, restam procedentes os questionamentos aduzidos a esse respeito pelos representantes.

Por outro lado, não merece acolhida o inconformismo demonstrado pela empresa Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda., atinente à forma de pagamento à contratada, após a disponibilização por esta dos créditos aos respectivos beneficiários.

Nessa direção, a regra disposta no citado subitem 11.1, observa o entendimento desta Corte em relação à matéria consoante prejudgado no Processo



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



TC-012657.989.24-0, de minha relatoria, apreciado por este Plenário na Sessão de 24/07/2024, sendo de interesse a transcrição do seguinte trecho do respectivo voto:

Dando seguimento, impende observar que a polêmica acerca do momento adequado para o repasse, em favor das empresas administradoras de vale refeição ou alimentação, dos valores relativos aos créditos dos trabalhadores, à luz das regras de direito financeiro e modificações nas normas do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, foi endereçada por esta Corte, em Sessão Plenária de 10/05/2023, nos processos n.ºs TC-008227.989.23-3, TC-008232.989.23-6, TC-008333.989.23-4, TC-009051.989.23-4 e TC-009106.989.23-9, com acolhimento do voto proferido pelo e. Conselheiro Robson Marinho⁵.

Em linhas gerais, firmou-se, naquela oportunidade, a orientação de que as quantias disponibilizadas nos cartões dos contemplados com tais benefícios materializam despesa pública, devendo, por essa razão, o processamento pertinente observar as etapas de empenho, liquidação e pagamento, em aderência aos artigos 62 e 63 da Lei Federal n.º 4.320/64. Essa orientação foi reiterada em julgamentos posteriores, ilustrados pelas decisões proferidas nas Sessões Plenárias ocorridas nas seguintes datas: 17/05/2023 – (i) TC-006679.989.23-6, TC-006709.989.23-0 e TC-006716.989.23-1, sob minha relatoria, (ii) TC-008415.989.23-5, sob relatoria do e. Conselheiro Dimas Ramalho, e (iii) TC-009903.989.23-4 e TC-010142.989.23-5, sob relatoria do e. Conselheiro Robson Marinho; 24/05/2023 – (i) TC-009058.989.23-7, TC-009162.989.23-0 e 009270.989.23-9, sob relatoria do e. Conselheiro Renato Martins Costa e (ii) TC-010229.989.23-1, sob relatoria do e. Conselheiro Dimas Ramalho; e, ainda mais recentemente, em 22/05/2024 – TC-010095.989.24-0, sob relatoria do e. Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo.

Nessa conformidade, em linha com a jurisprudência atual desta Corte, não merece guarida a pretensão de antecipação do adimplemento à operadora (facilitadora) do fornecimento do benefício.

Em razão do exposto, meu voto acompanha as conclusões do Ministério Público de Contas para considerar **parcialmente procedente** a Representação formulada pela empresa Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda. (TC-13596.989.24-4) e **procedente** aquela manejada pelo Advogado Felipe Dudienas Domingues Pereira (TC-013952.989.24-2), para o fim de se determinar à Prefeitura de Rancharia, que reveja a alínea ‘b1’ do subitem 4.1 do ato

⁵ EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. CHAMAMENTO PÚBLICO. INTERMEDIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES COM VALE-REFEIÇÃO. CREDENCIAMENTO. REPASSE DOS CRÉDITOS RELATIVOS AOS CARTÕES DOS BENEFICIÁRIOS. ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO MÁXIMO DE 0,90. REDE MÍNIMA DE ESTABELECIMENTOS POR MUNICÍPIO. PRAZO PARA CADASTRAMENTO INICIAL DE 50% DA REDE PREVISTA. ARRANJO DE PAGAMENTO. AUDIÊNCIA PÚBLICA. PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Considerando que em contratos para fornecimento de vales refeição e alimentação a despesa pública corresponde à soma da taxa de administração superior a zero com o repasse dos numerários relativos aos créditos dos cartões dos beneficiários, este repasse é pagamento de despesa pública e deve respeitar os estágios dos arts. 62 e 63 da Lei 4.320/64.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



convocatório, bem como outros dispositivos que lhe sejam correlatos, excluindo a admissibilidade de proposta com taxa negativa.

Após proceder à correção determinada, os responsáveis pelo certame deverão atentar para o disposto no §1º do artigo 55 da Lei nº 14.133/2021, com a republicação do instrumento e reabertura de prazo para formulação de propostas.

Expeçam-se os ofícios necessários, encaminhando-se os autos, após o trânsito em julgado, ao arquivo.